

1017565-76.2022.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Fábio Henrique Falcone Garcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de atendimento automático que permitem o furto de informações quando da utilização de cartões bancários pelos correntistas. A realidade já se mostra presente nos meios policiais, trata-se de fato notório que independe de prova. A tese de que o cartão com chip é impossível de ser clonada é desafiada pela profusão de causas demonstrando o contrário. Por isso, impossível falar em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

3ª Vara Cível

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo - SP - cep 08040-000

1017565-76.2022.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1017565-76.2022.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Helena Aparecida Gonçalves da Silva e outro

Requerido:

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

CONCLUSÃO :

Promovo a conclusão destes autos ao Dr. FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA, MM. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível deste Foro Regional de São Miguel Paulista, Comarca de São Paulo. Eu, Natália de Aquino Cesário, Assistente Judiciário, subscrevo.

HELENA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA e MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA ajuizaram ação em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e SUPERMERCADO TRIALBA LTDA. Aduzem que Moisés, marido de Helena, realizou operações bancárias no terminal de autoatendimento dentro do supermercado (segunda requerida), no dia 26/04/2022. Alegam que quando Moisés estava saindo foi abordado por uma pessoa que realizou a troca de cartões. Afirmam que somente ao chegar em casa notaram que o cartão não era seu. Sustentam que houve um prejuízo financeiro estimado em R\$ 2.200,00 advindo de saques que desconhecem. Afirmam que há responsabilidade objetiva das requeridas. Pleiteiam a condenação das rés ao pagamento de R\$ 2.200,00 a título de danos materiais e R\$ 11.000,00 a título de danos morais.

Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos aos autores (fl. 22).

Contestação apresentada às fls. 29/36 pelo Banco Crefisa. Preliminarmente, pleiteia a retificação do polo passivo e alega ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não há comprovação de falha dos serviços prestados pela instituição financeira. Alega que as transações foram realizadas através de cartão magnético com chip e

mediante digitação de senha pessoal. Nega a existência e extensão dos danos. Contestação apresentada pela corré Supermercado Trialba. Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva. No mérito, alega que inexistente responsabilidade da requerida, tendo em vista que o fato narrado é imputado a terceira pessoa, restando configurado excludente de responsabilidade (fato de terceiro). Afirma que os autores não trouxeram provas das alegações. Nega a existência e extensão dos danos. Houve réplica (fls. 88/92).

É o relatório.

Defiro a retificação do polo passivo para constar BANCO CREFISA S/A.

A instituição financeira Crefisa é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que os autores impugnam falha na prestação dos serviços bancários. A corré Trialba também é parte legítima para figurar no polo passivo, visto que os autores relatam que a fraude bancária aconteceu dentro de suas dependências, com falha de vigilância da corré.

Possível o julgamento do feito no estado em que se encontra, consoante autorização contida no inciso I, do artigo 355 do CPC, por não haver necessidade de produção de outras provas, já que as questões envolvem discussão eminentemente jurídica e prova documental. Ademais, as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas.

A pretensão é parcialmente procedente,

Consoante boletim de ocorrência de fls. 20/21, os fatos ocorreram em 26/04/2022, no período matutino (por volta das 08h45). O autor alega que teria comparecido ao caixa eletrônico 24 horas para sacar a aposentadoria de sua esposa, tendo sido abordado por indivíduo que, sorrateiramente, efetuou a troca de seu cartão.

As transações contestadas dizem respeito saques que totalizam o valor de R\$ 2.200,00 (fls. 54/55).

Ao que consta nos autos, após a constatação, foi realizado boletim de ocorrência no dia 29/04/2022 (fls. 20/21).

Competia à instituição bancária demonstrar a regularidade das transações efetuadas em máquinas de autoatendimento, ainda que instaladas fora de suas agências físicas. Todavia, as requeridas não demonstraram interesse em dilação probatória.

Ausente prova da regularidade das transações, a fraude deve ser reconhecida, com correlato reconhecimento de falha da financeira.

Há falha no sistema de segurança, na análise do perfil de operações do usuário e nas demandas por autenticação de transações em máquinas de autoatendimento. As instituições bancárias potencializam seus lucros ao pulverizar caixas de autoatendimento fora de agências bancárias.

Há tecnologia de segurança disponível, que poderia evitar fraudes desse tipo, como é o caso de biometria ou reconhecimento facial. Nada obstante, as financeiras optam por procedimentos menos seguros, menos custosos, em razão de um cálculo de custo-benefício que certamente envolve a análise de risco de fraudes desse jaez.

Por se tratar de conduta ínsita ao risco de sua atividade, a ré deve responder objetivamente por danos causados aos consumidores. Neste sentido, em caso semelhante ao dos autos, o E. Tribunal de Justiça já decidiu:

Apelação - Serviços bancários - Ação de indenização - Autor abordado por terceiro quando utilizava caixa eletrônico 24 horas, posicionado no interior de supermercado, sendo vítima do chamado "golpe do cartão" - Operações realizadas na conta bancária com cartão de débito por terceiro, estelionatário, fazendo uso do cartão do autor e da senha dele, também obtida mediante fraude - Sentença de rejeição dos pedidos - Irresignação parcialmente procedente. Aparato eletrônico colocado pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de agilizar os negócios realizados com a massa consumidora. Desarrazoado pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para afastar ou minimizar o risco. Fraude de que trata a demanda em exame representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a colocação de câmeras de filmagem e gravação de imagens e de sons no ambiente dos terminais eletrônicos, como ocorre nos países ditos de primeiro mundo.

Utilíssima, outrossim, a adoção de sistema de detecção de operações que fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a autoria e legitimidade dessas operações. Consideração, ainda a respeito, de que as operações questionadas refugiam por completo ao perfil de utilização do dispositivo pelo autor. Inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira nessas circunstâncias. Aplicação da teoria do risco da atividade, expressa no art. 14 do CDC. Hipótese se enquadrando no enunciado da Súmula 479 do STJ. Procedente o pleito de restituição dos valores correspondentes às operações impugnadas. Dano moral também caracterizado, haja vista que, em decorrência dos indevidos lançamentos, no valor global de R\$ 3.074,40, ainda não restituídos, o autor, homem idoso e simples, se viu privado de quantias para ele consideráveis. Indenização por danos morais que se arbitra na quantia de R\$ 10.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Sentença parcialmente reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda. Deram parcial provimento à apelação (TJSP; Apelação Cível 1008008-11.2019.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 27/03/2020) - GRIFEI

Assim, não se pode culpar o correntista pela fraude praticada por terceiro. Resta saber qual a extensão da responsabilidade.

O Banco, como depositário, deve restituir os valores sob sua guarda, quando a retirada se dá sem culpa do correntista, como ocorreu no caso vertente. A culpa, já se disse, deveria ser provada pelo réu, que nada fez nesse sentido. Importante frisar que a responsabilidade é objetiva, pela falha do serviço e tem fundamento contratual e legal, consistente na responsabilidade decorrente dos riscos assumidos pela atividade altamente lucrativa da instituição financeira. Nesse contexto, não se há falar em culpa exclusiva da vítima. É preciso reconhecer que o sistema de segurança do banco réu é falho.

Há, hoje, inúmeros expedientes utilizados para a realização de clonagem de cartões bancários ou para se obter senhas de correntistas, ou mesmo para realização de compras e empréstimos por terceiros. Muitas vezes, os golpistas contam com o auxílio de funcionários infiltrados ou se utilizam de petrechos em terminais de atendimento automático que permitem o furto de informações quando da utilização de cartões bancários pelos correntistas. A realidade já se mostra presente nos meios policiais, trata-se de fato notório que independe de prova.

A tese de que o cartão com chip é impossível de ser clonada é desafiada pela profusão de causas demonstrando o contrário. Por isso, impossível falar em culpa exclusiva da vítima. Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479 que imputa responsabilidade objetiva às instituições financeiras pelos danos provocados aos consumidores em razão do risco de sua atividade em casos como o dos autos.

Constatada a fraude, o consumidor deve ser restituído das quantias indevidamente sacadas do valor disponível em sua conta bancária.

Não se deve reconhecer dano moral, contudo.

Os autores demoraram para informar a instituição financeira, o que induz à conclusão de que tiveram perda patrimonial relativamente pequena, em razão de fraude perpetrada por terceiro.

A ré tem responsabilidade objetiva pelo dano material, mas não pode ser responsabilizada pelo abalo moral na hipótese vertente, em que houve crédito inicial de valores, com descontos ulteriores, sem que se tenha observado perda de valores necessários para subsistência, pelo simples fato de o autor ser vítima de um delito, perpetrado por terceiros.

Tratando-se de hipótese de responsabilidade objetiva, a responsabilidade da financeira está diretamente relacionada ao grau de risco que sua atividade contribui para os danos materiais, mas em relação ao dano moral, exige-se responsabilidade por fato próprio. E não houve, com a devida vênia, uma postura que por si só justificasse a pretensão indenizatória dessa natureza, em face da ré. Destarte, como já explanado anteriormente, o supermercado requerido deverá responder solidariamente pelo dano material, tendo em vista que instalou em suas

dependências caixa 24 horas para atrair consumidores, devendo zelar pela segurança adequada. Registre-se que antigamente esses caixas vinham acompanhados de cabines individualizadas, com fechamento, para que ninguém ingressasse no local senão o correntista. Alterada a sistemática, permitiu-se difusão maior de caixas, o que atrai clientela também ao mercado, que recebe pessoas para finalidade diversa, mas que acabam seduzidos pela oferta em profusão de produtos a comércio e terminam por adquirir produtos para si, ainda que sem necessidade. Logo, há lucro que permite o vínculo entre a responsabilidade e o lucro inerente à instalação dessas máquinas. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e resolvo o processo com solução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, a devolverem aos autores o valor de R\$ 2.200,00, com correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o saque indevido e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade deferida aos autores.

P. R. I. C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022

FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
Juiz de Direito